

第52問

甲は、知人から大量にミネラルウォーターと酒をもらい、処分困っていたため、Aに売却して小銭を稼ごうと考えた。しかし、甲は、Aがケチな性格であるため、うまく言わないと買ってくれないと考え、Aに対し、「これは神の水と言われていて、本来なら1本500円もする品だが、俺とお前の仲だ、150円で売ってやる。それと、この酒は1本1500円だ。酒を売るには免許が必要だが、俺は免許があるから大丈夫だ。」と言って、ミネラルウォーターを1本150円で100本、酒を1本1500円で10本売却し、合計3万円の交付を受けた。

なお、ミネラルウォーター及び酒の適正価格は、それぞれ150円、1500円であり、甲は、法律上要求されている酒類販売業の免許を有していない。

甲の罪責について、論じなさい（特別法違反の点は除く。）。また、仮に、Aが、酒類販売業の免許がない者からは絶対に酒類の販売を受けないと考えていた場合はどうか。

第1 設問前段について

1 ミネラルウォーターの売却について

- (1) 甲は、Aに適正価格が1本150円のミネラルウォーターを1本500円であると偽って、1本150円で販売しているから、詐欺罪（246I）の成否を検討することになる。

もっとも、適正価格が1本150円の物を150円で売却していることから、Aに財産上の損害があるのかが問題となる（**論点** 詐欺罪の成立要件としての財産的損害の有無 ■ 予R2,旧H12-2,H22-2）。

総合 224 頁 論証 104 頁

- (2) 財産上の損害については、学説上、形式的個別財産説と実質的個別財産説の対立がある上（明文にない要件を付け加えるべきではないとして、「錯誤」の要件を限定することによって、処罰範囲を適正化させようとする立場もある。）、判例の立場についても評価が分かれている（一般的には、形式的個別財産説に親和的な立場だといわれているが、実質的個別財産説に親和的なものもある（大決昭3.12.21、最決昭34.9.28【百選Ⅱ48】、最判平13.7.19【百選Ⅱ49】）。後記注釈も参照）。

もっとも、ミネラルウォーターの販売については、いずれの立場からでも詐欺罪の成立を肯定することができる。

2 酒の売却について

酒の売却についても、財産上の損害の有無が問題となる。

形式的個別財産説からは、ミネラルウォーターの売却と同様、個別財産の喪失がある以上、財産上の損害の発生を肯定することができるが、実質的個別財産説からは、財産上の損害の発生を否定することになる。

第2 設問後段について

- 1 まず、形式的個別財産説からは、前段と同様の処理をすればよい。

- 2 これに対して、実質的個別財産説の立場からは、両論ともあり得る。

一つは、財産上の損害を否定する見解であり、財産上の損害の有無（詐欺罪の成否）は、あくまでも経済的な観点から判断すべきであるから、Aの個人的な意思や好みは考慮しないという考え方である。

もう一つは、財産上の損害を肯定する立場であり、免許がない者から購入することは取引リスクを高めるものであるため、そのような取引におけるリスクを回避するという目的は、保護に値するという考え方である。

※ 以上は、財産上の損害という記述されざる構成要件要素を要求する通説的見解から検討したものである。

これに対して、近時の判例は、欺罔行為における「重要事項」の問題として検討する傾向がある（最決平22.7.29【百選Ⅱ50】、最判平26.3.28【百選Ⅱ51】、最決平26.3.28、最決平26.4.7参照）。

近時の判例の傾向に従えば、上記それぞれの問題を「重要事項」性の検討に位置付けることになる（令和2年予備試験刑法出題趣旨も参照。なお、具体的な論述の流れは、論証集を参照のこと。）。

答案構成

第 1 設問前段について

1 ミネラルウォーターについて

詐欺罪（246 I）の成否

↓

財産上の損害の有無

↓

必要説

↓

実質的個別財産説

↓

あてはめ

↓

詐欺罪成立

2 酒について

財産上の損害の有無

↓

あてはめ

↓

詐欺罪不成立

第 2 設問後段について

1 財産上の損害の有無

↓

2 A の個人的な意思や好みを保護するものではないが、取引リスクは 財産上の損害といえる

↓

3 1 項詐欺罪成立

第1 設問前段について

1 ミネラルウォーターについて

(1) 甲がミネラルウォーターを「神の水」と偽り、これを1本150円で100本売り、代金1万5000円の交付を受けた行為について、「人を欺いて財物を交付させた」として、詐欺罪(246条1項)の成立可能性がある。

(2)ア ミネラルウォーターの適正価格は1本150円であり、甲は適正価格で売っていることから、財産上の損害の発生がなく、詐欺罪は成立しないのではないか。

イ そもそも、詐欺罪の成立要件として財産上の損害の発生を要求すべきか。

この点について、条文上かかる要件が要求されていないことを理由として、これを不要とする見解がある。

もっとも、詐欺罪は財産犯であるから、財産上の損害の要件が必要であると解すべきである。

ウ また、詐欺罪は、財物・利益という個別財産の移転を中核とする犯罪であり、全体財産に対する罪である背任罪(247条)と区別されるべきであるから、個別財産の喪失自体を損害と捉えるべきである。

ただし、詐欺罪も財産罪である以上、欺罔行為がなかったならば交付がなかったであろうといえる場合全てについて、財産上の損害を肯定するわけにはいかず、被害者が得ようとして得られなかった

1

ものが経済的に評価して損害といい得るという、実質的な財産上の損害の発生が必要である。

エ 本問では、Aが得ようとして得られなかったものは「1本500円相当の割高な神の水」という価値である。そうだとすれば、たとえば実際に払った150円が適正価格だとしても、この「500円相当の神の水」という価値は、経済的にみて損害といい得る。

(3) したがって、実質的な財産上の損害の発生は肯定できる。

以上から、甲にはミネラルウォーター代1万5000円について1項詐欺罪が成立する。

2 酒について

(1) 酒についても、甲はAにこれを適正価格で売却していることから、財産上の損害の有無が問題となる。

(2) 本問において、甲は酒類販売免許を有していないにもかかわらず、これを有していると偽って酒を10本売り、1万5000円の交付を受けている。

上記のように、売却価格は適正であったのだから、Aが得ようとして得られなかったものは、「甲の酒類販売業の免許」である。しかし、この免許は租税の確実な賦課徴収という税法上の観点から要求されているものであって、経済的に評価して損害と呼べるものではない。

したがって、実質的な財産上の損害は認められない。

(3) 以上から、Aから酒の代金1万5000円の交付を受けた行為につ

2

いて、1 項詐欺罪は成立しない。

第 2 設問後段について

1 設問後段では、A は、法律を犯すことを極度に嫌っており、酒類販売業の免許がない者からは絶対に酒類の販売を受けないと考えている。

この場合でも、酒の売却について実質的な損害がないといえるのか。

2 確かに、上記のように詐欺罪の財産犯たる性格からすれば、財産上の損害の有無（詐欺罪の成否）は、あくまでも経済的な観点から判断すべきであり、A の個人的な意思や好みを保護するものではないというべきである。

しかしながら、A が酒類販売業の免許がない者からは絶対に酒類の販売を受けないというのは、酒類販売の取引におけるリスクを嫌ったものであると解される。そうだとすると、A が得ようとして得られなかったのは、個人的な意思や好みではなく、取引におけるリスク回避であると解すべきであり、このような目的は、経済的観点からみて十分に損害として評価し得るものである。

したがって、この場合には、実質的な財産上の損害の発生を肯定することができる。

3 以上から、甲には 1 項詐欺罪が成立する。

以上